

1500188-83.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500188-83.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033697/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22843714 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 298/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KEVIN AUGUSTO MOREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

02/05/2022

Réu Preso

Em 02 de maio de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu KEVIN AUGUSTO MOREIRA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Almiro Campos Soares Junior OAB 272811/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Vanessa Rocha Serafim (GCM) e Daniel da Silva Martino (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada

excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu KEVIN AUGUSTO MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, em 05 de fevereiro de 2022, por volta das 21h19, na rua José Lencione, altura do nº 385, bairro Vila Primavera, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 13 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 12,2 gramas; 02 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 1,97 gramas e 02 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 2,02 gramas,, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta da exordial, o acusado praticava o tráfico na via pública, sendo que trazia algumas porções de drogas em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados, e mantinha o restante escondido no terreno baldio situado perto do "ponto de vendas". Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam informação de que KEVIN estava promovendo o tráfico. Os agentes públicos, então, no local apontado, avistaram o acusado, o qual, ao notar aproximação da viatura, mudou de comportamento. Houve a abordagem e, nas vestes íntimas de KEVIN, foram encontradas 02 porções de "maconha". Em seguida, debaixo do pé do acusado, foram localizadas 02 porções de cocaína e R\$40,00. Dando continuidade, no terreno baldio foram encontradas mais 13 porções de cocaína idênticas àquelas apreendidas com o denunciado. O réu foi notificado (fls. 97) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 105/113). Assim, por decisão proferida no dia 25 de abril de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 114/118). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, por outro lado, pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e da fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 20/21, bem como Certidões a fls. 22/23. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, afasto o pedido de conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente toxicológico, tendo em vista a alegação de usuário pelo denunciado. Ora, é necessário frisar que a submissão do agente processado criminalmente ao incidente de dependência toxicológica é critério do julgador e não direito do acusado (TJSP-Rel. Dante Busana - RJTJSP 118/563). Portanto, ainda que a pessoa se declare viciada ou dependente, tal afirmação não obriga, por si só, à realização do incidente, que somente deverá ocorrer quando houver dúvida sobre eventual dependência, nos moldes do artigo 149, "caput" do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente aos crimes de entorpecente. A dúvida somente surgirá se no curso do processo existirem elementos capazes de indicá-la, no que diz respeito à integridade mental do acusado ou quando sua conduta delituosa ocorreu em razão da dependência toxicológica. Raciocínio diverso obrigaria o julgador aos termos da manifestação unilateral do acusado, que certamente resultaria no atraso do término do processo, dada as sabidas dificuldades na conclusão do incidente em tempo razoável, ensejando indevidamente excesso de prazo na custódia cautelar do acusado. Deste modo, não será a simples afirmação do acusado no sentido de ser usuário ou dependente à droga que implicará em dever incondicional do juiz, a quem cabe zelar pela regularidade e andamento do processo, em determinar a realização do citado exame, devendo-se atentar ao comportamento do acusado, aos indícios e circunstâncias dos autos para que se possa superficialmente detectar a mínima

anomalia psicossomática do réu, capaz de justificar a instauração do incidente, consoante iterativo entendimento Pretoriano: “A simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o juiz do processo a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada. Precedentes do S.TJ e do C. S.T.F. Nulidade para cujo reconhecimento faz-se necessário percuente reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. Ordem denegada” (HC 16.327/SP – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – DJU 02.09.2002, p 211). E mais, outra circunstância relevante está associada ao disposto nos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06, segundo o qual a isenção de pena ou sua redução em função de eventual incapacidade plena ou parcial gize-se ao tempo do delito do delito, para determinar-se de acordo com esse entendimento. Na lição do Ilustre Jurista Roberto Lyra, ao discorrer sobre os requisitos da inimputabilidade, do sistema biopsicológico adotado tanto pela Parte Geral do Código Penal de 1.940 e do Atual (Lei 7.209/84), bem como pela Lei 11.343/06, leciona que expressão, ao tempo da ação equivale ao pressuposto cronológico, que juntamente com o requisito causal e consequencial formam o quadro da inimputabilidade do agente. Ora, o citado requisito cronológico somente estará presente, justificando assim a instauração do incidente, quando forem amealhadas aos autos provas concretas de que o acusado estava sob o efeito do uso de entorpecente no dia do delito do qual está sendo acusado, vale dizer, se a eventual dependência decorrente do uso crônico e prolongado da droga, tal como ocorre com a doença mental, lhe tivesse retirado a capacidade intelectual e de autodeterminação no momento da prática do fato considerado delituoso, o que inoocorreu no caso em apreço, nada tendo os agentes de segurança relatado neste sentido. Em síntese, como bem salientado pelo Ilustre Ministro Celso de Melo, no HC 70.268 na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a perícia somente será necessária quando presentes duas condições: a) quando houver dúvida a respeito do poder de autodeterminação do acusado, à vista de elementos existentes nos autos; e b) quando houver evidência que a conduta foi realizada em virtude de dependência do uso de substância entorpecente. In casu, nenhum dos requisitos acima elencados mostraram-se presentes, posto que, não obstante o acusado tenha se declarado usuário de drogas, não mencionou passagens por clínicas para tratamento de sua suposta dependência, bem como não revelou, em seu interrogatório judicial, qualquer sinal ou indício capaz de confirmar tal alegação, vale dizer, expressou-se de forma lúcida e articulada ao apresentar sua versão acerca dos fatos, inexistindo, assim, qualquer indício de comprometimento mental resultante do eventual uso de entorpecentes que fosse apto a justificar a instauração do incidente em exame. Ainda em sede preliminar, embora não tenha sido arguida nulidade pela defesa, o tema fora abordado nos questionamentos da defesa aos agentes de segurança, oportuno salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, os guardas civis municipais, no momento em que notaram o estado flagrancial, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014),

a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de “qualquer pessoa do povo” seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é

necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de "garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas", consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. In casu, o acusado foi surpreendido trazendo consigo drogas, legitimando sua prisão em flagrante e a atuação da Guarda Civil Municipal. E, conseqüentemente, sendo lícita a diligência dos agentes públicos. Superadas as questões acima, passo a análise meritória. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/77) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente incontestada. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 11), manteve-se silente. Em juízo, o réu disse que sabe que tem um passado, que quando passou com o Dr Fabricio confessou. Que é usuário e no dia dos fatos foi até o bairro Fundação, estava com cem reais, pediu dois pinos e duas buchas e esse rapaz lhe deu dois pinos e o restante do valor. Esse indivíduo correu para o mato e ele subiu na calçada e escondeu os dois pinos. Foi esculachado pelos policiais e não foi abordado pelos guardas que foram ouvidos nesta oportunidade, foi abordado pelo Adriano. Não apontou lugar nenhum. Não estava com blusa azul, estava com blusa vermelha. Os policiais falaram que encontraram a droga, isso não sabe dizer, pois não viu. Nega a confissão e nega ter apontando onde estava a droga. A única coisa que trazia consigo eram as duas porções de cocaína e uma porção de maconha. Esses guardas que foram ouvidos hoje também estavam presentes em sua outra prisão. Tem 21 anos. Tem passagem na Vara da Infancia e Juventude por trafico. Estava trabalhando como servente, de segunda a sábado e recebia todo sábado. E solteiro e não tem filhos. Tem uma condenação por trafico. O réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa admitiu a propriedade de parte do entorpecente que seria para próprio uso, negando ter confessado o comercio ilícito aos guardas municipais. De outro lado, o Guarda Civil Municipal Daniel da Silva Martino, em sede policial (fls. 09) relatou que, na data dos fatos, juntamente com sua parceira, estava em patrulhamento pelo local, bairro Fundação Manoel Guedes, o qual já é conhecido nos meios policiais pelo alto índice de tráfico de entorpecente. Naquela ocasião, foram acionados por um popular, o qual relatou para a equipe que no endereço Rua José Lencione, tinha um rapaz de nome Kevin, o qual estava vestindo uma blusa azul e boné preto, o qual também é conhecido pelos policiais, estaria traficando no local, escondendo a droga num terreno baldio e servindo os usuários (sic). Diante disso, se deslocaram até o local, onde presenciaram o suspeito, com as mesmas vestimentas, o qual ao notar a presença da viatura, mudou o seu comportamento, demonstrando um certo nervosismo, na sequência o abordaram, o qual foi identificado como sendo KEVIN AUGUSTO MOREIRA, o qual estava em frente ao numeral 385, de frente ao terreno baldio. Em revista pessoal, foram localizadas duas porções de maconha dentro da cueca, e mais duas porções de cocaína, as quais estavam escondidas entre os pés e os chinelos, além da quantia de R\$ 40, reais em espécie. Instado, o acusado confirmou está traficando e apontou onde estava escondido o restante da droga, a quais realmente estavam no

referido terreno baldio, dando continuidade a denúncia, localizaram os demais entorpecentes no mencionado terreno. Em juízo, reiterou com exatidão os fatos já declarados em solo policial. O réu já era conhecido dos meios policiais e já o abordou anteriormente, mas nenhum entorpecente foi encontrado, somente dinheiro, sendo que o réu não esclarecia a origem do dinheiro. O réu não aparentava estar sob efeito de substância, não disse ser usuário e não portava nenhum apetrecho para o uso da substância. Convergindo em mesmo sentido, a também Guarda Civil Municipal Vanessa Rocha Serafim, em solo policial (fls. 10), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, reiterou os fatos já alegados em solo policial, disse terem abordado o réu, que este havia saído a pouco tempo da prisão, que ele confessou o comércio e apontou onde estava escondida a droga e no local foram encontradas porções de cocaína idênticas as encontrada com ele. O réu já era conhecido dos meios policiais. Quanto ao dinheiro, o réu confessou que era do tráfico. Não sabe dizer o motivo pelo qual o réu não confessou os fatos em solo policial. O informante os abordou na rua de cima, bem no começo do bairro, acredita que na José de Paula Pinto, era um senhor. A Rua José Lencione era atrás da rua que o informante os abordou. O réu não estava em atitude de venda, havia acabado de sair e sentar no local onde foi abordado. Durante a abordagem o réu estava sozinho e quando que seria abordado tentou ficar próximo de outras pessoas. No momento da abordagem o réu foi afastado dos outros indivíduos. Não acionaram a polícia militar, porque se tratava de flagrante e qualquer do povo pode prender nessa situação. O réu não alegou que a droga era para uso, não tinha apetrechos para o uso e não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos guardas, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas em poder do réu (em sua cueca e entre seu pé e chinelo), bem como o restante do narcótico no terreno em frente do qual estava o acusado; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/77), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na

previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a localização do acusado em local conhecido pelo comércio de drogas; 4) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 5) o comportamento altamente suspeito do acusado, que, ao ver a viatura, mostrou-se nervoso; 6) a exata correspondência das características do réu, inclusive seu nome, com o traficante delatado que estava atuando no local dos fatos; e 7) a informação dos guardas, de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas, inclusive indicando onde estaria o restante da droga. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639,

740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 73/77) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. De fato, apesar de se tratar de réu reincidente, essa circunstância será apreciada em segunda fase, momento adequado para tanto, de modo que fixo sua pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Processo nº 0011412-35.2019.8.26.0624, fls. 23), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuida de réu reincidente. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando se tratar de réu reincidente, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu KEVIN AUGUSTO MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 600

(seiscentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu reincidente, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 40,00 - fls. 79), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Pelo Defensor do acusado e pelo representante do Ministério Público foi dito que manifestariam eventual interesse recursal dentro do prazo legal. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recursos pelas partes e, após, tornem os autos à conclusão". Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA